

1502218-54.2021.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/01/2022

... "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502218-54.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502218-54.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2264114/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2264114 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 5131/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANTONIO ROQUE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

Vistos.

Vistos

MARCOS ANTONIO ROQUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33, parágrafo primeiro da Lei n. 11.343/06, esse conforme aditamento de pags. 135/136, e 16, parágrafo primeiro, IV, da Lei n. 10.826/03, tudo porque no dia 28 de setembro de 2021, em torno das 1h50min, na Rua Flórida Paulista, n. 150, nesta cidade e comarca, mantinha em depósito e guardava, para fins de comércio ilícito, entorpecentes e mais arma de fogo, além de valor em espécie, R\$ 1.574,00.

Constou da denúncia e aditamento que o réu foi abordado por policiais militares na

porta de sua residência, com vistas à constatação da veracidade da informação de que ele mantinha drogas e armas na residência. Tendo o réu tudo confessado, franqueou a entrada aos policiais, ocasião em que a arma foi encontrada no interior do seu guarda-roupas, enquanto que dentro de uma sacola azul, na cozinha, foi localizado o dinheiro e, próximo à mesa, estavam dois galões contendo a substância entorpecente objeto de laudo próprio que constatou que se tratava de produto ilícito, qual seja, o da substância diclorometano (pags. 123/124).

A denúncia foi regularmente recebida em 08 de outubro de 2021 (pags. 85/86), e depois também recebido o aditamento, sob oportunas citação, além de vista e ciência à Defesa.

Foi colhida a prova oral, sob interrogatório que finalizou a instrução (pags. 135 e seguintes)

Em debates, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia, referindo-se às provas que assim lhe serviram para tanto e, depois, à pena que entendia cabível.

A Defesa, em memoriais, preliminarmente requereu o trancamento dessa ação penal sob o argumento de que os policiais se contradisseram, não tendo sido autorizados ao ingresso na residência do réu no horário noturno. A partir disso, referiu-se a recente entendimento do STJ que trata da questão relacionada a apreensões e flagrantes sob as circunstâncias desse caso, concluindo que a "(...) 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus de ofício para declarar a nulidade das provas obtidas por meio da medida de busca e apreensão ilegal contra um réu processado por tráfico de drogas e trancar o inquérito contra o mesmo" (pag. 150). Em outro item, indicou que a substância apreendida, "sozinha" ou sem combinação com outras, não se revelava ilícita, insistindo também por isso na absolvição.

Já sobre a arma, a Defesa refere-se ao fato de que o laudo a considera como de uso permitido, e que disso também deve decorrer a absolvição do réu, ou no mínimo a desclassificação para delito menos grave. Também indicou outros benefícios no caso de eventual penal inclusive o da compensação da agravante da reincidência com a da confissão (pags. 143/154).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em primeiro lugar, registro que essa sentença foi recebida em conclusão apenas nessa data, considerando o período de gozo de férias dessa magistrada, até 24 de janeiro desse ano.

Sequencialmente registro que, mesmo tendo a Defesa técnica se esmerado em seus argumentos iniciais, que indicou como preliminares, avalio que sem o exame aprofundado das provas, impossível a definição sobre o que então alegado, e disso já passo ao próprio mérito.

Realmente, o réu houve denunciado pela prática de tráfico de entorpecentes, na figura do art. 33, parágrafo primeiro da lei especial, além de incurso também no art. 16, da Lei n. 10.826/03, pela posse de arma de numeração suprimida.

Para a materialidade, do que tudo decorreu do encontro e apreensão de arma e substância entorpecente na residência ou domicílio do próprio réu, vieram juntados o auto de exibição e apreensão de págs. 9/10. Além disso, houve depósito judicial do referido valor apreendido (pág. 71) e realização dos laudos, o da arma (págs. 73/76) e o do componente químico (pags. 123/125).

No primeiro laudo mencionado, o resultado foi positivo para constatação de recentidade de disparo, sob mecanismos de disparo eficazes e ali contendo dois cartuchos de calibre 38 de chumbo nu, também eficientes. Constatou também que parte da numeração da mesma arma vinha dali suprimida ou oculta.

Já no exame químico toxicológico, ao serem examinados os conteúdos dos dois galões, em ambos foram detectadas a presença de DICLOROMETANO, substância que consta na lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes ou psicotrópicos.

Em Juízo, ocorreu que o réu confessou parte dos fatos, mas quis insistir na tese de que nada do que apreendido em seu poder decorreu de diligência ou ação lícita da polícia militar que, segundo ele, teria ingressado de forma não autorizada em sua própria residência.

Nesse ponto, já se adianta, os policiais deram versão diversa da do réu sobre as circunstâncias da abordagem, sustentando sempre que não se excederam ou descumpriram com a lei constitucional e penal garantista dos direitos do mesmo.

Em sentido oposto, o réu insistiu que foi surpreendido em sua casa quando estava dormindo, e isso então no período da noite, declarando que, assim que entraram na sua residência, os policiais já passaram a buscas, rasgando suas roupas e mesmo respondendo, de forma ríspida, que não precisavam de nenhum mandado. Daí o réu alegou que eles realmente encontraram uma arma, mas não a que restou apreendida e de numeração suprimida, mas uma outra de calibre 38, que antes pertencia ao seu pai.

A Defesa técnica realmente chegou a indagar aos policiais algo sobre terem “trocado” as armas, como se aquela exibida e apreendida fosse diversa da que encontraram na residência e com o réu. Nesse ponto, e de novo se adianta, os policiais sempre responderam que a única arma encontrada com o réu foi a que houve apreendida, e depois periciada, não havendo “troca” nenhuma.

Seguindo adiante, o réu admitiu que vinha mesmo na posse dos galões que foram também recuperados e apreendidos, ressaltando contudo que não disse aos policiais que a substância ali contida serviria à produção de lança-perfumes, e até sobre isso alegou que nem sabia muito bem o que seria aquilo. Ainda assim o réu admitiu que guardava tudo a mando de um terceiro cujo nome não quis declinar para que não sofresse represálias, sabendo que seria produto ilícito e mesmo servível ao mercado ilegal, não se podendo dizer que não reconheceu aquela prática portanto.

Os dois policiais vieram a Juízo e nos ditaram similares relatos, ou seja, de que apenas rumaram para a residência do réu, esse também fisicamente a eles descrito na ocasião, porque assim lhes foi passada uma denúncia, qual seja, a de que o mesmo, naquele endereço, vinha guardando drogas e arma. Os dois policiais disseram ainda que, a princípio, apenas diligenciaram visando reconhecer o local a eles indicado, mas disso se depararam já com o réu junto ao portão daquela sua residência, na área da calçada.

Os depoentes, e nisso no que nem foram contrariados pelo réu, declararam que não o conheciam antes, nem antes já tinham investigado algo do que se passava naquele endereço, ou seja, os agentes repetiram que tudo decorreu daquela específica notícia que receberam na mesma data dos fatos, quando um transeunte informou-lhes de que o réu promovia algo de ilícito naquela residência. Disso, tornaram a dizer que apenas ingressaram ali porque o réu, ao ser abordado antes e fora da casa, admitiu-lhes que mantinha a arma de fogo ali dentro, sendo essa a que veio recuperada no armário dele, entre suas roupas.

Os policiais também deram conta de que os galões, contendo uma substância química,

mais dinheiro em espécie, cerca de pouco mais de mil reais, também estavam no local, e de novo sobre a substância o próprio réu teria lhes admitido que seria a usada no fabrico de lança-perfumes, que depois eram vendidos em “baladas”.

Em suma, ao se confrontar esses depoimentos com a própria versão judicial do réu, e até do que ele em grande parte se dispôs a confessar, o que nos convence é o fato de que os policiais não teriam razão nenhuma para alterarem determinados aspectos do encontro e apreensão de ilícitos. Disso, nada nos convenceu de que eles poderiam ter se disposto a “trocarem” uma arma por outra. Simplesmente isso não faz mesmo nem sentido.

Contudo, mesmo do que até aqui registrado e analisado, o que nos faz endossar o pedido de absolvição da Defesa técnica decorre diretamente das citadas decisões dos Tribunais Superiores de nosso país. Aliás, anoto que esse mesmo Juízo, tantas vezes antes, entendeu mesmo de forma diversa, firmando a condenação de outros processados em circunstâncias similares, reconhecendo que vinham legal ou lícitamente flagrados em delitos permanentes.

Mas agora, em posição que se deve adotar, endossando-a aqui, Turmas penais do STJ unificaram o entendimento sobre a necessidade de prova de autorização do morador para ingresso da polícia nesse tipo de caso, como bem suscitado pelos memoriais escritos do réu.

Não só a Sexta Turma do STJ, mas também a Quinta do mesmo Tribunal vem ratificando o entendimento de que cabe ao Estado demonstrar, de forma inequívoca e inclusive por meio de registro escrito e de gravação audiovisual, o consentimento expresso do morador para entrada da polícia em sua casa - isso evidentemente, na falta de ordem judicial. Tais decisões vem se acumulando para casos de tráfico de drogas, ou seja, ainda que considerada a natureza permanente desse delito.

Tanto aqui, como naqueles casos que consagraram a improcedência de ações penais da mesma ordem, os policiais não foram capazes de providenciar provas específicas, que deveriam salvaguardar a licitude de suas diligências, como a do ingresso sob registro detalhado, com autorização por escrito, firmada ou até filmada, de morador, a indicação de testemunhas, a impossibilidade de ser suspendida aquela imediata ação da polícia para o subsequente pedido por mandado judicial, etc. Aqui especialmente nem sequer aquele mencionado relato do denunciante da noite dos fatos, que poderia equivaler aos exigidos indícios mínimos sobre a atuação ilícita do réu, aportou nos autos. Tal comunicação poderia ser transcrita ou formalizada ainda que sob o sigilo ou anonimato de dados do denunciante, o que tampouco ocorreu, tornando mesmo muito frágil a relação do ingresso dos policiais com as exigidas fundadas razões de que o réu cometia os ilícitos penais.

Sobre a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais, no caso de não provada, como aqui, a autorização do morador, as mesmas Superiores Instâncias já avaliaram que tais razões não podem decorrer apenas da denúncia anônima, mas de investigação específica da polícia por meio de campana, filmagem, fotos, essas dando conta, por exemplo, de movimentação não usual no interior da residência, sob alguma evidência concreta de que a residência vinha usada para o delito. Outros casos são cancelados, para o ingresso, pelos mesmos julgados, ou seja, há licitude do ingresso da polícia quando ninguém mora no local, se há notícia de disparo de arma de fogo, se é percebido odor de determinada droga, etc. De novo, no caso em análise, nesse processo penal, faltou-nos aquele relevante elemento que poderia ser trazido pelos agentes policiais de modo a justificar seus ingressos naquele horário, quando não provada a autorização do réu, ou de outro morador, para tanto.

Apenas como reforço, vale a indicação de que, embora muitos julgados ainda estejam sendo proferidos em sentido oposto ao que aqui se adota, contamos já com precedentes também do próprio E. TJSP, como nos fundamentos de Acórdãos proferidos,

por exemplo, na Apelação Criminal n. 000002387.2019.8.26.0548, da 12ª Câmara de Direito Criminal, ou nos da Apelação n. 1500329.36.2019.8.26.0530, da 13ª Câmara de Direito Criminal, entre outros.

Aliás, vale aqui a transcrição desse seguinte trecho proferido no Habeas Corpus n. 2285840-28.2021,8.26.0000, em Acórdão julgado pela 12ª Câmara de Direito Criminal do TJSP:

“Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE nº 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe: 8/10/2010). Com efeito: a) o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, embora tenha confirmado que a Constituição Federal dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito e, no crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo, ponderou a necessidade de demonstração prévia de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida; b) em razão do caráter permanente do delito de tráfico de drogas, o flagrante é possível a qualquer momento, não constituindo ilegalidade o ingresso dos policiais na residência, mesmo sem mandado de busca e apreensão, pois a regra constitucional da inviolabilidade do lar não socorre agente em situação flagrancial; c) no julgamento do RE 603.616/RO, todavia, o Excelso Pretório fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial (o que não se deu na hipótese presente).

Nesse sentido, entre outros, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: - “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito. 2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante. 3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, que teria sido obrigada a prestar informação falsa sobre o delito, exigiria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 1.512.826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020 - destacamos).

No caso concreto, os policiais ingressaram na residência, sem realizar qualquer tipo de investigação, sem consentimento do morador e sem situação de flagrante delito, o que, a meu ver, contraria a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (...)

(...)

Diante desse contexto, tenho que a forma como os agentes públicos entraram na casa onde estava o paciente, sem qualquer investigação prévia, não constitui fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que havia uma situação de flagrante delito, ainda que tenham sido encontradas e apreendidas drogas no quarto do paciente; não havia suspeita fundada de que naquele momento e local estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não.

Nesse sentido, e em situação bastante semelhante à dos presentes autos, recentemente decidiu a Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. FUGA ISOLADA DO SUSPEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE PROVAS CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No RE n.º 603.616/Tema 280/STF, a Suprema Corte asseverou que a flagrância posterior, sem demonstração de justa causa, não legitima o ingresso dos agentes do Estado em domicílio sem autorização judicial e fora das hipóteses constitucionalmente previstas (art. 5º, XI, da CF). 2. Apesar de se verificar precedentes desta Quinta Turma em sentido contrário, entende-se mais adequado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento que exige a prévia realização de diligências policiais para verificar a veracidade das informações recebidas (ex: "campana que ateste movimentação atípica na residência"). 3. Recurso em habeas corpus provido para que sejam declaradas ilícitas as provas derivadas do flagrante na ação penal n.º 0006327-46.2015.8.26.0224, em trâmite no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP." (RHC 89.853/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020 destaque nosso)" (grifei).

Por fim, avalio relevante dizer que, a princípio e pelo que produzido para os autos, não há flagrante abuso ou excesso da equipe policial porque atuou de acordo com orientações que certamente se propagam ainda hoje, quando ainda são recentes as decisões precitadas e que invalidam apreensões sob aquele formato. Aos policiais, como se sabe, faltam treinamento e aparelhamento para situações desse tipo, e tanto que também naqueles habeas corpus de casos análogos já concedidos pelo STJ houve determinadas providências em prol da polícia militar, inclusive para a aquisição e distribuição de equipamentos eletrônicos, visuais ou de gravação, para a prova da exigida autorização do morador.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia e, como consequência, ABSOLVO MARCOS ANTONIO ROQUE, como incurso no art. 33, parágrafo primeiro da Lei n. 11.343/06, c.c. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, o que faço com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Como consequência da absolvição, também determino a imediata expedição do alvará de soltura ao réu, cumprindo-se com urgência com o que necessário a tanto.

A despeito da absolvição, pelo seu fundamento e da ilicitude inerente ao que apreendido, decreto o perdimento da substância ilícita e da arma de fogo, apenas se liberando, em prol do réu, o respectivo numerário também então apreendido.

Também determino que se encaminhe cópia da presente decisão ao Comando Superior da Polícia Militar para que possa ter ciência do nosso entendimento e de meios que possam ser adotados para provas fundamentais relacionada a ações desse tipo, tudo com base também no que determinaram as Instâncias Superiores, do STJ, conforme julgados já mencionados aqui antes.

P . I . C .

Ribeirão Preto, 23 de janeiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA